

1512437-60.2019.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".Tal entendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1512437-60.2019.8.26.0510 -
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512437-60.2019.8.26.0510 - 2019/001360

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS REINER MOUZINHO GALVAO e outro

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

CARLOS REINER MOUZINHO GALVÃO e LUANA CRISTINA DA SILVA, qualificados no inquérito, foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, assim porque, no dia 14 de novembro de 2019, por volta das 23h35min, na Avenida 4 JN, nº 1012, Terra Nova, nesta Comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, guardavam e tinham em depósito 118 (cento e dezoito) microtubos contendo a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 24,2 gramas, e 04 (quatro) invólucros contendo a substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol, totalizando peso líquido aproximado de 29,9 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 20/22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

(fls. 50/52).

Regularmente notificada a acusada LUANA (fls. 84) e notificado o acusado CARLOS REINER por edital (fls. 87), seguiu-se oferecimento de defesas preliminares em favor dos acusados (fls. 110/113), sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 23 de abril de 2021 (fls. 126/129).

Em instrução, foram ouvidas três testemunhas comuns, com posterior interrogatório dos acusados (fls. 152).

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a parcial procedência da ação penal, assim para condenar o acusado CARLOS pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, do Lei nº 11.343/06, com fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação de regime prisional inicial aberto. De outra parte, entendendo frágil a prova produzida, requereu a absolvição da acusada LUANA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 152).

Já ilustre Defensora Pública inicialmente observou que a apreensão de entorpecente decorreu de procedimento ilícito, com invasão de domicílio, comprometendo a materialidade delitiva, a determinar a absolvição dos acusados, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, sustentando frágil a prova produzida, requereu a absolvição dos acusados, nos termos do artigo 386, inciso VII, do mesmo Estatuto Processual Penal, observando, neste ponto, o princípio da correlação entre imputação e sentença, em relação à acusada LUANA, requerendo sua absolvição com fundamento também no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito irrogado aos acusados para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Tóxicos. Em caso de acolhimento da pretensão acusatória inicial, pugnou pela fixação das penas-bases nos mínimos legais, com o reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, no patamar máximo, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, anotando-se regime prisional aberto, em caso de reconversão, facultando-se, ainda, a interposição de recurso em liberdade e, por fim, a restituição dos valores apreendidos em poder dos Acusados (fls. 152).

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Inicialmente cumpre dizer que, nos termos do disposto no artigo 385, do Código de Processo Penal, poderá o juiz proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha reclamado a absolvição ou a desclassificação, já que não se adotou em nosso ordenamento o sistema acusatório puro, não se entrevendo violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, tampouco conflito entre aquela disposição e o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal.

Ademais, não se pode ignorar que, superada a fase inquisitória, com a deflagração da ação penal, emerge ao acusado o direito a um julgamento a partir do contraditório estabelecido, não se podendo afastar o exercício da jurisdição na solução material do conflito (art. 5º, XXXV, CF).

E a solução do conflito passa pelo impulso oficial do processo, conferindo inclusive ao julgador a iniciativa de diligências e de medidas cautelares, cabendo a ele o exame da prova produzida, da qual é destinatário natural, para, a final, obter o desiderato da busca da verdade real, limitando-o apenas a motivação expressa de seu livre convencimento.

Acresça-se que a pretendida vinculação do juízo ao reclamo de absolvição do Ministério Público, além de transferir indevidamente ao órgão acusador o exame das provas produzidas, suprimindo, ademais, o conhecimento do que deduzido na amplitude do contraditório, violando o princípio da indeclinabilidade da jurisdição, importaria ainda em afronta, via oblíqua, ao princípio da indisponibilidade e da obrigatoriedade da ação penal.

Deste modo, o jus puniendi não é regido por critérios de oportunidade ou conveniência, submetendo-se ao princípio maior da busca da verdade real, por isto que o juiz poderá proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha reclamado a absolvição (art. 385, CPP), como reconhecido, inclusive, pela

Suprema Corte (HC 69.957-0, DJ 25.03.1994) e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (HC 76.930/SP, DJ 5.11.2007, e Resp nº 738.550/ES, DJ 18.12.2006).

Seja como for, no mérito, procede mesmo em parte a pretensão acusatória.

Atribui-se aos acusados a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, assim porque, agindo em concurso e com identidade de propósitos, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, guardavam e tinham em depósito os entorpecentes indicados na denúncia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 20/22, com resultado positivo para cocaína, identificando-se também em parte da substância apreendida o elemento tetraidrocanabinol, responsável pelos efeitos estupefacientes da maconha. Sustenta-se que a materialidade do delito estaria comprometida diante da ilícita apreensão do entorpecente, decorrente de violação de domicílio. Entretanto, respeitado o entendimento exposto, não se entende tenha ocorrido a mácula apontada. Como exposto pelos Policiais Militares que realizaram a apreensão, o local era conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecente. No dia dos fatos, quando em patrulhamento, o acusado foi avistado e empreendeu fuga para a moradia, por isto foi abordado e, naquele local, apreendeu-se certa quantidade de entorpecente, alguma quantia em dinheiro e ainda petrechos.

Ademais, conforme exposto pela acusada Luana, ao ver uma Policial militar sobre o muro, cuidou em abrir o portão, franqueando o ingresso na moradia.

Deste modo, o ingresso no imóvel decorreu das circunstâncias apontadas, com a fuga do acusado, a indicar a prática de delito de natureza permanente, cujo estado flagrancial se protraí no tempo, excepcionando a inviolabilidade do domicílio, além da indicação de que o ingresso foi franqueado, afastando a objeção de ilicitude que teria comprometido a materialidade do delito.

Controverte-se sobre a posse e a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Ouvido em Juízo, o acusado CARLOS afirmou que, na ocasião dos fatos, estava jogando video game junto com sua companheira LUANA, quando ouviram barulho na parte externa da moradia. Ao verificar o que ocorria, avistou dois Policiais Militares em seu quintal e outros pulando o muro. Diante da situação, sua companheira abriu o portão para que eles adentrassem na residência, sendo então informado de que havia denúncia de tráfico no local, por lá se apreendendo tão somente certa quantia em dinheiro, uma parte falsificada, e sacolas para embalagem de alimentos.

Acrescentou que LUANA permanecia bastante em sua moradia, mas que pernoitava na residência dos genitores dela. Por fim, afirmou que era usuário de entorpecentes e que foi agredido na ação policial, exibindo as lesões corporais suportadas à D. Autoridade Policial (fls. 152).

A acusada LUANA, a sua vez, indicou que estava jogando video game com seu companheiro, quando ouviu alguém mexendo no portão da moradia. Avistaram uma Policial em cima do muro e, por isso, afirmou que abriria o portão para o ingresso. Afirmou que, a época, eram usuários de entorpecentes, mas negou a existência de algum entorpecente no interior da moradia. Por fim, relatou que, durante as diligências, permaneceu na parte externa do imóvel, mas viu seu companheiro sendo agredido (fls. 152).

Todavia, a versão deduzida pelos Acusados foi contrariada pela prova produzida.

A testemunha Rafaello, Policial Militar, afirmou que, na ocasião dos fatos, quando em patrulhamento pelo local, conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes, avistaram o Acusado defronte à moradia, Com a aproximação ele correu para o interior do imóvel, por isto que foi em seguida abordado, confirmando que estava realizando o comércio ilícito, com indicação de que havia entorpecentes no interior da moradia. Realizada uma busca no imóvel, seguiu-se a apreensão de dinheiro, entorpecente - maconha e cocaína que estavam armazenados no interior de um guarda roupa - além de petrechos (fls.7/8). Após a apreensão, o Acusado que estava bastante agressivo, tentou novamente fugir, mas conseguiram detê-lo, com emprego de força física (fls. 152).

O policial militar Roberto igualmente informou que na ocasião, quando em patrulhamento, notaram que o Acusado demonstrou nervosismo e empreendeu fuga no

momento em que se aproximaram, por isto que em seguida foi abordado. Questionado sobre a fuga, afirmou que teria ficado assustado ao avistar a equipe policial, já que estava realizando o tráfico ilícito de entorpecentes. Realizada uma busca no imóvel, seguiu-se a apreensão de dinheiro, entorpecente, consistente em maconha e cocaína que estavam armazenados no interior de um guarda roupa. Após a apreensão do entorpecente o Acusado tentou novamente empreender fuga, mas foi contido, com emprego de força física (fls. 152).

Neste mesmo sentido o Policial Militar Carlos (fls. 152).

Como se tem consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais militares envolvidos nas diligências. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu). Como se vê, os elementos probatórios produzidos possibilitam seguro juízo de convicção sobre a imputação dirigida ao acusado CARLOS, revelando não apenas a posse do entorpecente mas também a sua destinação mercantil, assim diante da quantidade e diversidade de entorpecentes, embalados de forma individualizada, além da confissão informal realizada.

Entretanto, em relação à acusada Luana a situação é diversa, como reconhecido pelo Parquet.

De fato, conquanto existam indícios que concorrem em desfavor da Acusada, por isto o recebimento inicial da denúncia, o fato é que, após o desenvolvimento de atividade cognitiva mais aprofundada, remanescem questionamentos sobre se efetivamente tinha conhecimento da existência do entorpecente no local e se estava auxiliando no comércio ilícito, a determinar mesmo a improcedência da pretensão acusatória em relação a ela.

Por fim, não há igualmente demonstração bastante de que os valores apreendidos decorressem da atividade ilícita, a afastar a pena de perdimento, promovendo oportunamente a restituição devida.

Isto considerando, passo à dosagem da pena de CARLOS.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais e judiciais favoráveis, possível seja fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

De outra parte, a pena-base cominada deve ser reduzida em função do que disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Este dispositivo legal cuida da possibilidade de operar-se a redução da pena, quando se tratar de réu primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e que não esteja dedicado ao comércio ilícito.

O acusado é primário, não havendo indicação suficiente, por ocasião dos fatos, de que estivesse já dedicado à atividade criminosa, de tal modo que deve a pena-base ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda. Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 caput e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa".

Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo". Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016).

Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06).

Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo.

Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda.

Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes.

No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória e:

i) com fundamento no artigo 33, "caput", c.c. §4º da Lei nº 11.343/06, e artigos 44 e 46, do Código Penal, CONDENO o acusado CARLOS REINER MOUZINHO GALVÃO à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1(um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo; e

ii) com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO a acusada LUANA CRISTINA DA SILVA da imputação contra ela dirigida na denúncia. Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto.

Oportunamente, promova-se a restituição dos valores apreendidos e o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA